

1522270-22.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522270-22.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522270-22.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2179134/2022 - 93º Distrito

Policial - Jaguaré, DB1633-3/2022 - 93º Distrito Policial - Jaguaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ ELIAS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 941.22

VISTOS.

ANDRÉ ELIAS SANTOS e JOHNNY VITOR OLIVEIRA COSTA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 288, § único, 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c 29, caput, por duas vezes, e 158, §1º e §3º, c/c 29, caput, por duas vezes cada, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal; pois consta que, a partir de data incerta até 02 de julho de 2.022, nesta cidade, associaram-se, com ao menos outros dois indivíduos não identificados, para o fim específico de cometer crimes de roubos e extorsões.

Consta que, em 1º de julho de 2.022, à rua Belmonte, 957, Lapa, São Paulo/SP, ANDRÉ ELIAS SANTOS e JOHNNY VITOR OLIVEIRA COSTA, previamente ajustados e com unidade de propósitos com outros indivíduos desconhecidos, participaram efetivamente da subtração, em proveito comum, executada por dois indivíduos não identificados,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, do Honda/Civic, placas EMA1213, Iphone 11, dinheiro e seis cartões bancários de K. A. B.

Consta, outrossim que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima, ANDRÉ ELIAS SANTOS e JOHNNY VITOR OLIVEIRA COSTA, previamente ajustados e com unidade de propósitos com outros indivíduos desconhecidos, participaram efetivamente do constrangimento de K. A. B., executado por dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para todos vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

É dos autos que, em 02 de julho de 2.022, por volta de 01h, à rua Mário de Oliveira Dick, São Paulo, ANDRÉ ELIAS SANTOS e JOHNNY VITOR OLIVEIRA COSTA, previamente ajustados e com unidade de propósitos com outros indivíduos desconhecidos, participaram efetivamente da subtração, em proveito comum, executada por dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, do GM/Tracker, placas EXQ0080, Iphone e cartões bancários de A. A. C. Consta, por fim, que, nessas mesmas condições de tempo e lugar, ANDRÉ ELIAS SANTOS e JOHNNY VITOR OLIVEIRA COSTA previamente ajustados e com unidade de propósitos com outros indivíduos desconhecidos, participaram efetivamente do constrangimento de A. A. C., executado por dois comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para todos vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

A denúncia foi recebida à fl. 113.

Foram apresentadas defesas preliminares às fls. 131 e 151.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, as duas vítimas, quatro testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados. Em debates, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa de André, em memoriais a fls. 173/191 preliminarmente, requereu a juntada aos autos das filmagens do shopping e da loja. No mérito, pediu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de estelionato, nos termos do art. 171 do Código Penal; a absolvição do crime de roubo e reconhecimento da mera participação no crime de extorsão, conforme o artigo 29, §1º, do Código Penal. Ademais, pugnou pela aplicação no crime de roubo apenas da majorante pelo emprego da arma de fogo; afastamento do parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal; aplicação do princípio da consunção na fixação da pena. Caso não seja aplicado este princípio entre os delitos e não haja o reconhecimento do concurso formal entre as infrações, pede que seja reconhecido, ao menos, a existência da figura prevista no artigo 71 do Código Penal. Também requereu a aplicação do artigo 29, §1º, do Código Penal em grau máximo, já que sua atitude pode ser considerada de menor importância. Por fim, pediu que a pena seja mantida no mínimo patamar legal, que haja a fixação de regime inicial mais brando e requereu a justiça gratuita.

Por sua vez, a Defesa de Johnny, em memoriais a fls. 193/205 requereu, preliminarmente, a juntada da mídia da audiência de custódia. Em seguida, pugnou pela absolvição do réu, já que nenhuma das vítimas o reconheceu. Caso esse não seja o entendimento, requer a desclassificação da imputação criminosa para o crime de estelionato, nos termos do artigo 171 do Código Penal. Pede o reconhecimento da menoridade relativa (art. 65, I, CP); o reconhecimento do crime único entre os roubos e as extorsões; a absorção do delito pelo crime de roubo. Se não for reconhecido o crime único, requer o reconhecimento da continuidade delitiva. Também pede o afastamento da majorante atinente ao emprego de arma e a fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

DECIDO.

Afasto de plano as preliminares arguidas pelas Doutas Defesas.

E isso porque, além de já haver sido superado o momento oportuno para o requerimento de tais diligências, tenho que as imagens da audiência de custódia, bem como dos estabelecimentos comerciais, em nada trarão qualquer elucidação que

pudesse favorecer a busca da verdade real, além das provas que já instruem os autos.

No mais, tenho que as imagens eventualmente existentes nos estabelecimentos comerciais já não mais estão disponíveis, eis que apagadas de tempos em tempos. Já com relação às imagens da audiência de custódia, bem poderiam ter sido solicitadas pela própria defesa, de maneira que, com relação a elas, operou-se a preclusão. Superadas as questões, no mérito a presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, 35 e 39, bem como pelos boletins de ocorrência de fls. 43 e 60, dando conta dos bens das vítimas que os réus subtraíram, além dos objetos comprados com os cartões das vítimas.

A autoria é igualmente inconteste.

Na fase inquisitiva, os réus presos em flagrante, declararam que receberam os cartões de Neguinho para que efetuassem as compras no shopping. Ainda, o réu Johnny declarou que tem conhecimento que Wellington, vulgo Neguinho, tem esses "lances" de sequestro, pois Neguinho recentemente apareceu na comunidade com "carrões"; que Wellington lhe entregou um telefone para o interrogado que tinha fotos dos cartões e senhas e era para manter contato com Wellington pelo celular e que foi por este telefone que os Policiais desta Distrital fizeram contato com Wellington e um tal de Vira-Copo onde negociaram a libertação da vítima. Que o interrogado esclarece que quando foram fazer as compras no Shopping estava com André e Hugo e que Hugo já tinha saído da loja quando os Policiais chegaram no local, fls. 07/08.

Em Juízo, o réu ANDRÉ declarou que encontrei o Johnny onde fui cortar o cabelo. Eu conhecia ele e ficamos conversando. Veio um carro preto, chamou ele, ele foi lá, pegou uns cartões e voltou. O carro foi embora e Johnny me chamou para fazer umas compras com ele no shopping. Ele falou para eu ficar tranquilo que os cartões eram quentes. Eu não sabia que era coisa errada. Nisso ele foi com outro menino, e eu fiquei cortando o cabelo. Aí fiquei curioso e fui lá ver o que eles estavam fazendo. Eu fiquei ali com ele, os policiais chegaram, nos algemaram e nos levaram. Fomos levados na viatura, fomos agredidos, eu falei que não sabia de nada, que fui lá de curioso. No primeiro convite que ele fez para eu ir com ele, eu não fui. Tenho 20 anos de idade, nunca fui processado antes, não conhecia a vítima nem os policiais.

O réu JOHNNY declarou em juízo que era um sábado quando isso aconteceu. Eu estava no cabelereiro, quando Wellington me chamou e me apresentou alguns cartões, e perguntou se eu tinha coragem de comprar roupa, que era cartões clonados de banco. Ele me deu um celular para me comunicar com ele. Ele disse que eu não teria problema, que eram cartões de banco, que não ia dar nada. Então eu aceitei a proposta dele, que ficou de me dar umas roupas. Voltei para o salão, onde o André estava e chamei ele para ir comigo. Ele disse que não tinha coragem, que não ia. Nisso, Bahia que estava lá também, disse que ele tinha coragem e ia comigo. Então fomos na loja, escolhemos as roupas, Wellington ia mandar as senhas e o tamanho das roupas pelo celular que ele me deu. Bahia saiu da loja, e quando eu ia sair, Wellington disse para eu não ir embora, que já estavam chegando as senhas dos outros cartões. Ele me passou uma nova senha, eu comecei a escolher mais roupas, e quando fui pagar, colocar a senha, o André chegou. Ele disse que veio só de curioso e perguntou se tinha dado certo. Eu disse que tinha colocado a senha e estava esperando. Nisso os policiais chegaram e levaram a gente para delegacia, onde fomos agredidos, eles disseram que tinham vítimas, queriam saber onde estavam as vítimas. Tinham muito policiais do GOE, anti-sequestro. Eu nem sabia onde eu estava. Tenho 20 anos de idade, nunca fui preso antes, não conhecia as vítimas nem os policiais. O contato que falava comigo no telefone tinha o nome de Neguinho. Não sei quem é Vira Copo. Foi Wellington que me indicou a loja Fly, eu conhecia ele da comunidade que eu morava. Não sei o que ele fazia. Bahia é o Hugo, que estava comigo. Na delegacia eu falei tudo isso, que o André chegou depois, e também falei que eu não sabia no que Wellington era envolvido.

Ocorre, porém, que as negativas dos réus não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual não convenceram.

As confusas e lacônicas versões apresentadas pelos acusados, somente vem a demonstrar que na ocasião, ambos efetivamente tiveram participação nos fatos que ora se tratam.

A tese do acusado André no sentido de que somente teria ido ao shopping por curiosidade mostra-se no mínimo pueril e em absoluto não convence. Tanto é assim que fez ele também uso dos cartões das vítimas, fato este que revela que não se tratou de mera curiosidade mas de efetiva participação nos crimes tanto de roubo como de sequestro.

Além disso, temos que ambos os acusados mantinham contato com os executores materiais, através de telefones celulares, através dos quais recebia as senhas das vítimas e realizava as transações comerciais. E mais, foram os próprios acusados que forneceram aos policiais informações que possibilitaram a libertação das vítimas dos cativeiros que estavam. Ou seja, se sabiam eles que as vítimas estavam em cativo, tiveram sim, participação efetiva em todos os crimes dos quais são acusados.

Não se pode crer que os réus fossem acusados da prática de crimes de tamanha gravidade, não tivessem eles efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existem indícios a indicar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar os réus, ou mesmo acusá-los falsamente. As vítimas, em seus depoimentos em sede policial, alegaram que ficaram vendadas. Em juízo, a vítima, A.A.C., declarou que não tenho certeza se os réus estavam no dia, porque no momento em que fui abordado, já fui vendado. Eu marquei o endereço com uma menina que conheci, quando cheguei ao local, vi que esse veículo estava chegando também, do interior do carro saiu um indivíduo armado, me rendeu, me vendeu, me colocou no banco de trás desse veículo corsa e me levaram para um cativo, onde fiquei por mais de oito horas. Eu ouvi conversas, no sentido de que dois integrantes da quadrilha haviam sido presos e logo depois me libertaram. O que me abordou estava armado, com uma arma de cano longo. Eles exigiram as senhas dos cartões e senhas bancárias. Essa compra que tentaram fazer com meu cartão não foi aprovada. Eu fui abordado por volta de uma hora da manhã, do dia 1 para o dia 2. Eu fui liberado por volta das 18:30 do dia 2. No ambiente em que eu estava no cativo, não havia outra vítima. Eu ouvi a conversa, que tinham pego dois, mas não ouvi nomes. Depois eles me disseram que quando eu fosse dar meu depoimento era para eu dizer que havia sido rendido em Cotia e não no Butantã, mas eu fui realmente rendido por eles no Butantã. Soube, na delegacia de polícia que os réus foram presos porque estavam tentando fazer compras com o meu cartão.

Já a vítima K.A.B., declarou, em juízo, que eu estacionei meu veículo e, quando saí, fui abordado por dois indivíduos. Eles me colocaram no banco de trás, um ficou comigo e o outro assumiu o volante. Pegaram todos os meus bens, pegaram um terceiro indivíduo e me levaram para um cativo, onde fiquei até o dia seguinte. Eles pegaram todas minhas senhas e cartões, contas, agências. Meu veículo foi subtraído e depois encontrado. Essa compra no valor aproximado de três mil reais foi feita com meu cartão. Não tive contato com esses réus. Enquanto eu estava no cativo eu ouvi o nome Wellington. Eu fui abordado no dia primeiro, de manhã e fui liberado no dia seguinte, por volta das quatro horas. Não posso afirmar com certeza se havia outra vítima, mas eu ouvia passos no mesmo cativo que eu. Não posso afirmar, mas acredito que sim. Eles falaram no telefone, já prenderam dois com cartão, no shopping, então é para me soltar e também a outra vítima. Eu não fui solto logo após, acredito que duas horas depois do telefonema. Sou proprietário da empresa Ezecon. Eu me lembro que os executores eram negros, os três eram negros. Um deles tinha sotaque do Nordeste. Eles estavam armados.

Muito embora as vítimas não tenham tido contato com os réus, motivo pelo qual foram incapazes de reconhecê-los, temos que as provas dos autos se encaixam como uma luva, e levam de forma irrefutável ao caminho condenatório. Até porque os acusados foram denunciados como participantes, eis que, embora não tivessem tido participação direta, foram os responsáveis pelas compras e saques feitos com os cartões das vítimas. Suas condutas amoldaram-se perfeitamente aos tipos penais descritos na denúncia, de maneira que a ausência de reconhecimento, em nada abala o édito

condenatório.

Atenta, assim, ao relato prestado pelas vítimas, observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Mas nem se cogite que a condenação teria por fundamento unicamente as declarações das vítimas. Isso porque a testemunha M. R. N. declarou na fase inquisitiva que sua funcionária Viviane informou que dois indivíduos estavam fazendo muitas compras e o valor girava em torno R\$ 13.000,00 (treze mil reais) e que um dos cartões acusou bloqueio por limite, sendo que por fim os indivíduos conseguiram autorização para a compra de R\$ 3.483,00.

A testemunha V. T. C., declarou, em sede policial, que dois indivíduos que tentavam efetuar compras de grande valor e o cartão que usavam apontava um bloqueio para efetivar a compra, e que aquelas compras chegava em torno de R\$ 12.000,00 e que as compras foram divididas em alguns cartões, sendo uma no valor de R\$ 3.483,00 que foram debitadas no cartão que constava o nome de K. A. B.; que soube que os Policiais Civis foram acionados pelos seguranças do Shopping e que os indivíduos foram abordados pelos Policiais e com os mesmos foram encontrados quatro cartões de crédito em nome de A. A C., K. A B. e um outro da Empresa Ezeecom T Ltda; esclarece que, quando da prisão, estes olharam para a declarante e a encararam em tom ameaçador, deixando-a apavorada, temerosa por sua vida, e que teme por represálias, pois informou que nasceu e cresceu na comunidade e que sabe como funciona.

Em juízo, declarou que essa compra de três mil, eu não estava no horário, eu já tinha saído, porque foi a noite e eu já tinha ido embora. No dia seguinte, eu estava no horário do almoço, pediram para eu atender os rapazes porque eu era responsável pela loja, eu fui ajudar. Foi quando os policiais chegaram, anunciando que eles estavam presos. Eles estavam de máscara, e não olhei direito. Não tenho condições de reconhecer os réus porque não fui eu que atendi eles, e também em razão do tempo. Na delegacia, realmente eles olharam para mim, eu tenho medo dessas coisas, deles acharem que fui eu que falei. Quem atendeu os réus foi a Raiane. Maurício não estava na loja. Não sei quem chamou a polícia. Na delegacia, os policiais comentaram que foram os seguranças do shopping que chamaram eles. Tenho certeza que os indivíduos que foram presos foram os mesmos que tentaram fazer as compras com os cartões.

A testemunha R. F. A., declarou na fase inquisitiva que estava trabalhando quando três homens chegaram a loja e começaram a fazer compras, que um dos homens separou várias peças de roupas, pagou com cartão e saiu da loja e essa compra foi no valor de R\$ 3.483,00; que os outros dois indivíduos continuaram a fazer compras, e avisou ao proprietário da loja que aqueles possíveis clientes iriam fazer uma compra de um valor muito grande; que foi surpreendida com a chegada dos Policiais Civis, que deram voz de prisão aos indivíduos e informaram que eles estavam fazendo compras com cartões de vítimas de sequestro. Em juízo, declarou que eles chegaram, tinham outros clientes na loja. Primeiro entraram dois, veio essa compra de três mil e pouco que deu certo. Depois um foi embora e o outro ficou na loja. Ele escolheu as coisas, tentaram passar o cartão, não passou. Em seguida os policiais chegaram e algemaram eles. Não tem como reconhecer os réus porque não olhei para o rosto deles, e eles estavam de máscara.

Veja que os funcionários das lojas onde os réus faziam compras com os cartões das vítimas, os reconheceram em sede inquisitiva, e o reconhecimento por elas feitos, foi devidamente confirmado em Juízo.

Ainda, os policiais civis responsáveis pela investigação e prisão dos réus, Fernando Sydio de Souza Thomé e Kaue Guazzelli Gomes declararam em juízo, de forma

firme e segura e em uma só voz que nós fomos acionados pela segurança do shopping, porque nós já tínhamos visitado esse shopping dias atrás porque outras vítimas haviam sido sequestradas e foram feitas compras com os cartões delas. Pedimos então aos seguranças do shopping que se notasse algo suspeito, compras grandes feitas com dois ou três cartões. E foi o que ocorreu, no dia dos fatos, fomos acionados e logramos deter os dois réus tentando realizar compras nessa loja Fly by Fly. Inclusive um deles estava ao telefone, acreditamos que pegando as senhas. Os cartões apreendidos estavam em nome das vítimas que estavam sequestradas. Na delegacia de polícia, o telefone que estava com os réus não parava de tocar. Contatamos os familiares das vítimas, e tomamos conhecimento de que estavam desaparecidas. Uma delas era do interior. Até que atendemos um telefonema e negociamos a libertação da vítima Anderson. Reconheceram os réus em audiência. O policial que negociou a libertação das vítimas foi o policial João. O contato que mais ligava era alguém que estava gravado com o nome Vira Copo. Os réus confessaram que receberam os cartões das vítimas para fazerem as compras. O shopping que eles estavam faz divisa com Osasco. Outras equipes estavam pelas ruas em buscas das vítimas. Havia também familiares de outra vítima que estavam em contato com a equipe Anti-sequestro, de maneira que essas diligências estavam sendo feitas enquanto os réus estavam na delegacia. Os cartões estavam com os dois réus. O celular estava com o Johnny.

Assim como as vítimas as testemunhas e os policiais eram estranhos aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ª T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Duas foram as condutas perpetradas pelos agentes, com dolos distintos. No tocante ao roubo, houve a subtração, com emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, dos bens das vítimas. Em um segundo momento, a intenção dos agentes, além da subtração dos bens, ainda com grave ameaça com emprego de arma de fogo, dirigiram-se a obter das vítimas indevida vantagem econômica, consistente na entrega de senhas de cartões bancários.

Assim, embora as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto fático, ensejam o reconhecimento de dois delitos diversos, quais sejam, o roubo e a extorsão, em concurso material. Ainda que se tratem de delitos de gênero material, são infrações que não possuem a mesma espécie jurídica, decorrentes de desígnios completamente autônomos.

Lecionando sobre o tema, o autor JULIO FABRINI MIRABETE, na obra CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, 7ª edição, editora ATLAS, ao comentar os artigos 157 e 158 do Código Penal, explica que: "Se o agente, após a consumação do roubo, mantém a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar um saque bancário, há concurso material entre roubo e extorsão qualificada." (pg. 1089).

Também explica o tema o ilustre Guilherme de Souza Nucci: "A Lei 11.923/2009 criou a figura típica do sequestro relâmpago, inserindo no art. 158, § 3º, do Código Penal, uma circunstância nova de execução do crime de extorsão, bem como a previsão da possibilidade de dois resultados qualificadores (lesão grave e morte). No mesmo parágrafo, houve o aproveitamento para a inclusão de uma qualificadora (crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica), com pena de reclusão, de 6 a 12 anos, e multa, mas também trouxe a figura qualificada pelo resultado, ou seja, se do sequestro relâmpago advier lesão grave, a pena será de reclusão, de 16 a 24 anos; se ocorrer morte, a pena será de reclusão, de 24 a 30 anos. Em primeiro

lugar, convém destacar inexistir qualquer conflito aparente de normas ou confusão legislativa pela simples vigência do disposto no art. 157, § 2º, V, do Código Penal ('se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade'). Já sustentávamos anteriormente, conforme se constata nos comentários a esse dispositivo, ser inaplicável a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, ao caso do sequestro relâmpago. Para tal situação, seria necessária a tipificação em roubo seguido de sequestro, por ausência de outra figura específica. A partir da inclusão do § 3º o art. 158, passa-se ao tipo preciso de extorsão, cujo constrangimento é voltado à restrição da liberdade da vítima como forma de pressão para a obtenção de vantagem econômica (...)." (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, editora Forense, 15ª ed., pág. 917).

E não é apenas a doutrina que segue esse entendimento. Eis a jurisprudência de nossas duas cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC 113900 SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.11.2014). "(...). Na hipótese vertente, verifica-se que o Paciente foi condenado como incurso nas sanções dos crimes de roubo e extorsão, sendo, pois, inaplicável a regra da continuidade delitiva. Embora os delitos de roubo e furto pertençam ao gênero dos crimes contra o patrimônio, não são da mesma espécie, razão pela qual não se configura hipótese de crime único ou continuidade delitiva, mas sim o concurso formal ou material. Assim, na esteira da orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça, crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo dispositivo legal, isto é, que possuem o mesmo tipo fundamental, abrangendo as formas simples, privilegiadas e qualificadas, tentadas ou consumadas. (...). Ante o exposto, DENEGO a ordem" (STJ HC 162.862 SP, Rel. Minª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.05.2012). Tal a hipótese dos autos. Os agentes, mantendo as vítimas subjugadas, subtraíram seus pertences, e ainda, constrangeram-nas a fornecer senhas, de modo que incorreram nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material. Dessa maneira, portanto, afastam-se as teses de crime único e absorção do roubo pela extorsão suscitadas pelas cultas Defesas dos réus.

Quanto às majorantes, que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pela dinâmica dos acontecimentos ou declarações das vítimas firmes no sentido.

Assim, tem-se dos autos, que os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, bens de propriedade das vítimas, contra quem foram exercidas a grave ameaça e restrição de liberdade, mediante emprego de arma de fogo.

Referente ao roubo com emprego de arma de fogo restou igualmente comprovada. A despeito de não ter havido apreensão da arma, o relato das vítimas foi firme no sentido de que os comparsas dos réus estariam armados no momento do assalto.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de

testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010). "A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Trata-se de crimes de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes, e emprego de arma (artigo 157, §2º, inciso II e § 2º A, inciso I), e extorsão qualificada, pelo concurso de pessoas, emprego de arma (artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal). Apenas um reparo merece a peça acusatória e tal se dá com relação ao crime de quadrilha. E isso porque não se comprovou a evidência que os acusados fizessem parte da quadrilha formada pelos executores materiais. Desta forma, a absolvição com relação a este crime é de rigor.

Em arremate, a continuidade delitiva é patente nos autos. Veja que os acusados, agindo com outros indivíduos, mediante grave ameaça, subtraíram bens de duas vítimas diferentes, de maneira que pelas condições de tempo, lugar e modus operandis, uns é tido como continuação do outro, configurando na hipótese, o crime continuado.

Logo, conforme todos os documentos constantes nos autos, não há que se falar em ausência de robustez probatória a fim de um édito condenatório.

Consoante o examinado, pois, percebe-se que os réus tiveram efetiva participação nos delitos, agiram conscientemente de modo que não cabe a alegação de menor participação ou falta de ciência quanto a existência de vítimas e nem mesmo a desclassificação para o crime de estelionato disposto no artigo 171 do Código Penal. Então, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Verifico que os réus são primários e não ostentam antecedentes criminais, assim nesta primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o roubo, e 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para a extorsão qualificada.

As penas bases já fixadas no mínimo legal não podem ser reduzidas pela menoridade relativa nos termos da Súmula 231 do STJ.

Verifico que incidem sobre o crime de roubo duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Dessa forma, aumento a pena dos réus em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Quanto ao crime de extorsão, verifico que foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma, causas de aumento tipificadas no artigo 158, §1º, do Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de extorsão qualificada. O que se verifica na verdade é falta de técnica legislativa, como se vê na seguinte decisão do STJ: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática

do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Recurso especial provido." (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016) "HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.

(...) 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos. (...) (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)"

Assim sendo, aumento a pena do crime de extorsão em mais 1/3, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Restando patente a continuidade delitiva (art. 71, caput do CP), posto terem sido dois crimes praticados, aumento a pena base dos crimes em 1/6, para, não havendo outras circunstâncias, tornar definitiva a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para extorsão e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dias) de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Vale registrar a orientação, salvo hipótese especialíssima, de que o número de infrações cometidas serve como critério para determinar o quantum de aumento do art. 71, caput, do Código Penal.

A este teor, confira-se entendimento do C. STJ: "De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no crime continuado, o critério utilizado para determinar o quantum de aumento guarda relação com o número de infrações praticadas" (HC 184816/SP - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Quinta Turma - Dje 01/07/2013). Nessa linha, adota-se como regra, porque normais as condições de cada delito, para dois, o aumento de 1/6; três, majoração de 1/5; quatro, acréscimo de 1/4; cinco, exacerbação de 1/3; seis, incremento de 1/2; sete ou mais crimes, eleva-se em 2/3, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros, apud Código Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, p. 360/361.

Somadas as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, pois trata-se de concurso material de crimes, torno-a definitiva em 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

O dia multa será fixado no valor mínimo legal, ante a falta de motivação para estabelecê-lo em valor diverso.

Os condenados, iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145). Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado" (TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de tratar-se de roubo, praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar os réus, a cumprirem, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, como incursos nas sanções dos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71 e artigo 158, §§ 1º e 3º, também por duas vezes, na forma do artigo 71, em concurso material, todos do Código Penal. Julgo ainda, improcedente a presente ação penal para absolve-los das penas do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais aos condenados. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital. Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,

proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos.

Concedo a ambos os condenados o benefício da Justiça Gratuita.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA